

1501283-87.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196830/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 26247884 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2196830 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVANDRO RAMOS AUGUSTO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501283-87.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501283-87.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196830/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 26247884 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2196830 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVANDRO RAMOS AUGUSTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

NIVANDRO RAMOS AUGUSTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 329, caput, duas vezes no artigo 129, § 12, três vezes no artigo 147, todos do Código Penal, e uma vez no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, porque, segundo narra a denúncia, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 09h45min, na Rua Dois, 1, bloco B, casa 3, no bairro Renascer, nesta cidade, o acusado foi surpreendido

por policiais militares trazendo consigo, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 18,110g de cocaína em pó e 31,280g de maconha, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e/ou psíquica; também porque no mesmo dia, horário e local, o acusado se opôs à execução de ato legal dos policiais militares Flávio Henrique Thomazin, Tiago Balera Garcia e Anderson, mediante violência, causando lesões corporais de natureza leve nos dois primeiros (175/177); e ainda porque no mesmo dia, horário e local, o acusado ameaçou os policiais militares Flávio Henrique Thomazin, Tiago Balera Garcia e Anderson de causar-lhes mal injusto e grave.

Narra a denúncia que o acusado realizava o tráfico de drogas, trazendo consigo os entorpecentes dentro da cueca. O acusado estava sentado na calçada próximo ao local dos fatos, juntamente com mais um indivíduo, aguardando eventuais compradores, quando, por volta das 09h45min, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina passaram pelo local e ao perceberem a aproximação da viatura, NIVANDRO e o outro indivíduo saíram correndo e ingressaram na residência situada no local dos fatos, sendo que NIVANDRO, ao correr, segurou os entorpecentes que trazia consigo na cintura para não perdê-los. Diante da atitude suspeita e dos indícios de crime, inclusive porque os militares não conseguiram identificar se de fato NIVANDRO guardava na cintura arma de fogo ou drogas, os policiais desembarcaram e saíram ao encalço dos indivíduos, adentrando no imóvel que estava com o portão e a porta da sala aberta, mas conseguiram deter somente NIVANDRO, uma vez que o outro indivíduo conseguiu escalar o muro para o imóvel dos fundos. Narra que o acusado foi colocado sentado no chão, por procedimento de segurança, já que os policiais ainda estavam tentando localizar o outro indivíduo evadido, ficando o acusado sob a guarda do policial militar Tiago. Narra que no momento em que o policial Tiago solicitou que NIVANDRO levantasse para ser realizada a busca pessoal, o acusado, ao se levantar, agrediu o militar, desferindo um soco no rosto dele, continuando as agressões com chutes e outros socos na face, na tentativa de conseguir se evadir do imóvel. Em virtude da reação de NIVANDRO, os policiais Flávio e Anderson tentaram contê-lo, oportunidade na qual também foram agredidos com socos e chutes, sendo realizado o uso progressivo da força para deter NIVANDRO e colocá-lo novamente no solo para tentar algemá-lo, contudo, o acusado continuou resistindo à abordagem mediante violência contra os policiais, chegando a segurar a arma do policial Tiago, tentando sacá-la enquanto ainda estava no chão, não conseguindo devido à trava do coldre. Narra que o policial Flávio, em razão da resistência e agressões do acusado, ficou com uma escoriação e um pequeno corte na canela da perna direita e a mão direita luxada, ao passo que o policial Balera ficou com um hematoma no queixo e uma escoriação na canela, e que o policial Anderson sofreu um chute na cabeça, o qual não provocou lesões, todavia, sua boina ficou suja de terra. Narra que finalmente algemado, o acusado ainda ameaçou os policiais, dizendo que os mataria. Depois, submetido à revista pessoal, no interior de sua roupa íntima foi localizada uma sacola plástica transparente contendo 61 pinos de cocaína, 10 saquinhos tipo ziplock de cocaína, e mais 4 porções de maconha. Narra que o acusado foi conduzido à UPA NORTE, sendo que ao ser colocado no compartimento de presos, ele desferiu chutes contra a viatura e, visando evitar danos ao patrimônio público, os policiais amarraram as pernas do acusado com um pedaço de fio que encontraram no local.

Notificado (fl. 216), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 234/239). Recebida a denúncia (fls. 242/245), o réu foi citado. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado (fls. 396/401).

A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, com exceção dos delitos de ameaça e contravenção penal, ao passo que a Defesa sustentou a absolvição, alegando falta de provas e ainda alegou nulidade das provas por ter ocorrido invasão de domicílio.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiro nenhuma ilicitude há de ser reconhecida.

O crime de tráfico de drogas é permanente, logo, possível o ingresso em residência, quando existirem indícios da prática de crime. Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito, o que se verificou nesse caso. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 05/11/2015 o Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (grifo meu).

Neste caso havia fundadas suspeitas, mormente em razão da atitude do acusado, que ao visualizar os policiais empreendeu fuga, segurando algo na cintura, adentrando em uma residência que estava com portão e portas abertas.

Além do mais, em decisão recente, a Ministra Rosa Weber, assentou que “A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 213.852/RJ, 1ª Turma, j. 30 de maio de 2022).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

Na fase extrajudicial o acusado disse que trabalha recolhendo materiais para reciclagem e reside somente com sua esposa e filho. Na data dos fatos, por volta

das 09 horas, saiu para pegar reciclagem, indo primeiro na casa de sua irmã, no Bairro Renascer, onde havia várias pessoas, inclusive sua irmã Mariana e quatro crianças pequenas. Após cerca de trinta minutos adentrou correndo naquele local o adolescente Léo, de 12 anos, o qual começou a falar: "Polícia, Polícia", e logo em seguida surgiram os policiais do BAEP, invadindo o local, abordando todos e dizendo: "perdeu, perdeu". Frisou que ninguém tinha autorizado a entrada dos policiais no imóvel. Um dos policiais comentou com os outros policiais: "olha quem está aqui", acreditando que o policial fazia referência a outro episódio no qual ele foi preso por policiais do BAEP. Em seguida o policial começou a perguntar: "o que tinha dispensado, cadê o canhão, cadê as drogas?", acrescentando que todos estavam dentro da residência. Disse que não tinha nada e por ficar nervoso por conta das acusações e da presença sem autorização dos policiais dentro da casa, acabou desacatando-os, dizendo pra eles "caçarem traficante na rua e bandidos, porque naquele local não tinha", acrescentando que os policiais retiraram todos de dentro da casa, ficando somente ele e um policial moreno, o qual começou a agredi-lo fisicamente, com chutes e socos, sendo que caiu no chão e então os outros policiais começaram também a agredi-lo. Após as agressões, algemado, os policiais disseram: "não falamos que iríamos te pegar, agora pelo menos você vai ficar 2 anos". Negou que estivesse em poder de drogas ou que estivesse sentado com outro indivíduo na frente da casa. Negou também ter fugido ou agredido os policiais, bem como negou ter tentado pegar a arma de um policial quando estava no chão. Depois que foi algemado foi colocado dentro da viatura, negando ter ameaçado os policiais ou tentado chutar o compartimento de preso, mas confirmou ter sido amarrado pelos policiais com fios nas pernas. Experimentou lesões e foi levado à UPA/Norte. Indicou que há dois meses tinha sido preso por uma arma de fogo que foi "plantada" por alguns policiais, os mesmos que participaram desta ocorrência, mas seus nomes não apareceram.

Interrogado em Juízo o acusado confessou que realmente estava defronte a casa de sua irmã com outra pessoa vendendo drogas. Estava vendendo cocaína no local e fugiu com a presença da polícia, adentrando na casa da irmã. Os policiais queriam que falassem quem era a pessoa que teria fugido e como não informou foi agredido, primeiro pelo policial Balera e depois pelos demais policiais. Os policiais apertaram seu pescoço e chutaram seu rosto. Diante das agressões, com dificuldade para respirar, ficou desesperado e tentou se desvencilhar, pois temia ser morto. Ao tentar se desvencilhar, movendo pés e mãos, acabou atingindo os policiais, mas frisou que sua única intenção era cessar as agressões. Ficou muito lesionado em razão das agressões sofridas. Não proferiu ameaças de morte. Vendia drogas há cerca de uma semana e em razão de dificuldades financeiras. A maconha era para seu uso, mas se alguém pedisse também venderia. Trabalhava como catador de material reciclável.

O policial Flávio Henrique Thomazin e Tiago Balera Garcia, no auto de prisão em flagrante, afirmaram que durante patrulhamento pelo Bairro Renascer visualizaram dois indivíduos na calçada, os quais, ao avistaram a viatura, adentraram correndo na residência, sendo que um deles segurou algo na cintura, não dando para perceber se era alguma arma de fogo ou drogas. Desembarcaram e também adentraram no imóvel, esclarecendo que o local estava com o portão e a porta da sala aberta. Já no interior do imóvel conseguiram somente deter o acusado, visto que o outro conseguiu escalar o muro e fugir. O acusado trata-se daquele que durante a fuga tinha colocado a mão na cintura. Enquanto tentavam localizar o outro indivíduo, o acusado ficou sob a guarda do policial Balera e no momento em que este solicitou que o acusado levantasse para ser realizada a busca pessoal, ao se levantar, o acusado desferiu um soco no rosto do policial Balera, continuando as agressões com chutes e outros socos, visando também conseguir se evadir, contudo, o policial Flávio e o policial Anderson conseguiram contê-lo, mas também foram agredidos com socos e chutes. Depois de muito esforço, quando o acusado já estava no chão, ele ainda segurou a arma do policial Balera, tentando sacá-la, mas não conseguiu por conta da trava do coldre. Algemado e revistado, no interior de sua roupa íntima localizaram

uma sacola plástica transparente contendo em seu interior 61 pinos de cocaína, 10 ziplock de cocaína, e 4 porções de maconha. O imóvel não foi revistado por conta da intensa reação do acusado, o qual ainda proferiu ameaças contra os policiais, dizendo que os mataria. O policial Flavio ficou com uma escoriação e um pequeno corte na canela da perna direita e a mão direita luxada. O policial Balera ficou com um hematoma no queixo e uma escoriação na canela, ao passo que o policial Anderson sofreu um chute na cabeça, o qual não provocou lesões, mas sua boina ficou suja de terra. Depois, ao ser colocado no compartimento de presos da viatura, o acusado desferiu chutes e para evitar danos amarraram as pernas do acusado com um pedaço de fio que acharam no local. Não conheciam o acusado, mas depois que irradiaram a ocorrência soube que em outras duas ocasiões o acusado já tinha resistido à prisão, inclusive causando danos a uma viatura.

No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. O policial Flávio Henrique Thomazin afirmou que decidiram pela abordagem em razão de terem avistado o acusado correndo, segurando algo na cintura e ainda acompanhado de outro indivíduo, suspeitando que pudesse ser arma ou droga. O acusado foi abordado perto da varanda e ficou com o policial Balera, ao passo que ele e o policial Anderson foram até os fundos do imóvel, mas o outro indivíduo conseguiu fugir. No imóvel havia uma mulher e algumas crianças. Quando retornaram se depararam com o acusado agredindo o policial Balera com socos e ainda tentando se apoderar da arma do policial, razão pela qual o imobilizaram mediante uso de força. As drogas foram localizadas na cueca do acusado. Confirmou que outra viatura prestou apoio, mas chegaram após a imobilização do acusado. Por sua vez, o policial Tiago Balera Garcia, disse que o local da abordagem é conhecido ponto de narcotráfico. Passavam pelo local e notaram que o acusado e outro indivíduo saíram correndo e ainda que o acusado segurava algo na cintura, suspeitando que pudesse ser arma ou drogas. Desembarcaram da viatura e determinaram que parassem, mas eles não obedeceram e ingressaram correndo na residência. O acusado foi abordado logo após a garagem e foi levado a este local, onde permaneceu sentado, ao lado do depoente, ao passo que os outros dois policiais foram até os fundos da casa, tentando localizar o outro indivíduo, mas este pulou o muro e conseguiu fugir. Em seguida, quando determinou que o acusado se levantasse para ser revistado, ele o agrediu com um soco no queixo, além de tapas e chutes, visando também se evadir, contudo, auxiliado pelos outros policiais e, mediante uso de força, conseguiram imobilizá-lo. Frisou que durante a imobilização o acusado desferiu chutes e socos, pois estava muito descontrolado, causando lesões em todos os policiais. O acusado ainda tentou se apoderar de sua arma de fogo. Durante a abordagem o acusado o ameaçou de morte em várias ocasiões, além de tentar quebrar o vidro da viatura, razão pela qual optaram por amarrá-lo.

Mariana Ramos Augusto, irmã do acusado, na fase policial, asseverou que na ocasião estava em sua casa, acompanhada dos filhos e do acusado, quando seu cunhado Júnior, de 12 anos, chegou correndo e, em seguida, os policiais invadiram sua residência, alegando que estavam perseguindo Júnior porque ele tinha corrido. O acusado disse aos policiais que Júnior era uma criança, mas os policiais já tinham colocado o acusado e Júnior sentados na residência, esclarecendo que as demais crianças continuavam no local. Ao saberem do nome do acusado os policiais disseram que ele tinha se envolvido com uma ocorrência policial e em seguida começaram a agredi-lo com socos e chutes. A depoente tentou intervir e foi impedida, chegando a ser empurrada contra a parede, e um policial apertou seu pescoço. Os policiais também empurraram as crianças, causando medo nelas. Depois foram retiradas do imóvel e os policiais continuaram agredindo o acusado. Em seguida o carregaram, aparentando estar o acusado inconsciente, notando que as pernas, braços e pescoço estavam amarrados com um fio. O acusado foi colocado na viatura como um "porco". Foi ameaçada pelos policiais para não ir até a delegacia e narrar os fatos. Não experimentou lesões por conta das agressões dos policiais. Ouvida em Juízo a testemunha confirmou que o acusado de fato portava drogas, razão pela qual tentou fugir dos policiais, mas logo parou e levantou as mãos. O irmão é usuário de

maconha, mas a cocaína e o crack se destinavam à venda, pois a situação financeira da família estava muito precária. Afirmou que o acusado não agrediu os policiais e durante as agressões que sofria tentou fugir, mas levou uma rasteira, caindo de "cara no chão". O acusado foi amarrado como um animal.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.

A materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 11/15 (boletim de ocorrência), fls. 18/19 (auto de exibição e apreensão), fls. 20/23 (fotografias das drogas), fls. 30/31 (fotos das lesões nos policiais), fls. 170/173 (exame químico-toxicológico), fls. 174/177 (exame de corpo delito) e pela prova oral.

De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado, mormente porque a prova dos autos demonstra que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado, se destinava ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem.

Ressalte-se a confissão judicial, merecendo destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288). No mesmo caminho segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi - Data de registro 23/04/2010).

Ademais, os policiais foram taxativos em afirmar que apenas efetuaram a abordagem porque o acusado e outro indivíduo não identificado empreenderam fuga logo que avistaram a aproximação da viatura, tratando-se de local conhecido como ponto de narcotráfico e ainda que o acusado segurava algo na linha da cintura, suspeitando que poderia ser arma de fogo ou drogas. Apenas o acusado foi abordado, destacando os policiais que o imóvel estava com as portas abertas. Em poder do acusado apreenderam diversas porções de cocaína e algumas de maconha. Ademais, os policiais foram incisivos em afirmar que o acusado ofereceu resistência, inclusive com emprego de violência, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Ressalto que além da droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a tentativa de fuga, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida do acusado, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser

sustentado.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa ao réu, que sequer conheciam.

Aliás, como já se decidiu, “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

“Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido” (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de o réu trazer consigo os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De igual forma restou evidenciado que o acusado se opôs à execução de ato legal dos policiais, mediante violência contra eles. Nesse sentido a narrativa uníssona dos policiais, que ficaram lesionados. É certo que a testemunha Mariana afirmou que o acusado não agrediu os policiais, mas seu depoimento deve ser visto com ressalvas por ser irmã do réu.

Com relação ao crime de resistência acrescento ainda que a vítima não é apenas o

funcionário público, mas também a própria dignidade e respeito devidos à Administração Pública e se consumou com o emprego de violência contra o ato legal do policial, não importando que após o ato acabe sendo executado. Se os policiais agiram com excesso no uso da força para conter o acusado não afasta a configuração do delito de resistência e já foi determinada a apuração dos fatos (fls. 88).

Assim, perfeitamente tipificado o delito, pois, agiu o réu imotivadamente, opondo-se contra ato legal de servidores públicos, policiais militares devidamente fardados, resistindo, dificultando ação dos policiais, que no momento tentavam abordá-lo.

Aliás, como afirmado acima, não há nos autos nenhuma notícia de que os policiais tivessem motivos para imputar acusação falsa ao réu e, conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese em testilha.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Também está comprovado o crime de lesão corporal praticado contra os policiais Flavio e Tiago. Os exames de corpo delito concluíram que os policiais sofreram lesões corporais de natureza leve (fls. 174/177) e o §2º do artigo 329 do Código Penal prevê expressamente que “as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.

A causa de aumento prevista no §12 do artigo 129 do Código Penal também está configurada, porquanto o crime foi praticado contra policiais militares, no exercício da função.

Por outro lado, no tocante aos demais delitos (ameaça e vias de fato), como bem exposto pela acusação, a prova se revela frágil, mormente pela falta do depoimento do policial Anderson. Ademais, o crime de ameaça não restou suficientemente comprovado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, para condenar é preciso prova incontestável, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Impõe, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas quanto aos crimes de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo as penas no mínimo, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade (tráfico de drogas); em 2 meses de detenção (resistência); e em 3 meses de detenção (cada crime de lesão corporal). Deixo de considerar a condenação certificada a fls. 68 como Maus Antecedentes porque é pela prática do crime de posse de entorpecente. Com efeito, embora essa magistrada entenda de forma diversa, curvo-me ao entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga

para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com 'advertência sobre os efeitos das drogas', 'prestação de serviços à comunidade' e 'medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo', mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência. 5. Recurso improvido." (REsp 1672654/SP, 6ª Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018; no mesmo sentido: AgRg no HC 539720/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18/02/2020, DJe de 02/03/2020 e AgRg no AREsp 1679045/AC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Na segunda fase, quanto ao crime de tráfico de drogas, incide a atenuante da confissão espontânea, contudo, como as penas já estão no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Para os demais crimes não há agravante ou atenuante para ser considerada, permanecendo as penas lançadas acima.

Na terceira fase observo que é caso de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o acusado é primário, sem antecedentes criminais, não há qualquer notícia de que integre organização criminosa e se dedique a atividades criminosas. Assim, reduzo as penas anteriores em 1/6 (um sexto), resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero que o acusado está sendo condenado nessa sentença pela prática de outros delitos e praticou o crime estando em liberdade provisória. Levo em consideração ainda e, supletivamente, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas.

No tocante aos crimes de lesão corporal, presente a causa de aumento por ter sido praticada contra policiais, no exercício da função, majoro cada pena em 1/3 (um terço), resultando em 4 meses de detenção.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam definitivas as penas acima lançadas, que somadas resultam 4 anos e 2 meses de reclusão e 10 meses de detenção, além do pagamento de 416 dias-multa.

Como a pena para o tráfico supera 4 anos descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e descabe também para os demais ante a violência empregada e o disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena de prisão fixo no semiaberto. Ante a primariedade do réu e não se tratando de quantidade expressiva de drogas apreendidas o regime intermediário é suficiente para prevenção e reprovação do

crime.

O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. Os crimes que cometeu e as penas a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão.

Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I – O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II – A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III – Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285).

O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançou o tempo que lhe permitiria a progressão de regime. Ademais, este não é o único requisito e somente ao Juízo das Execuções Criminais cabe analisar o preenchimento dos requisitos legais.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu NIVANDRO RAMOS AUGUSTO como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; no artigo 329, caput; e duas vezes no artigo 129, caput e §12, todos do Código Penal, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, no mínimo a unidade.

Sem prejuízo, absolvo-o da acusação de cometimento dos delitos capitulados no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs.

Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA